

1503325-91.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... que não interferem na tipificação do tráfico de entorpecentes (guardar e ter em depósito), único crime aqui tratado.

De igual modo, não há como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Marcelo admitiu que é usuário de drogas desde os 16 anos de idade. Informou ter optado por se envolver com o tráfico porque estava passando por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1503325-91.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503325-91.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Augusto da Conceição Rodrigues

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, qualificado à fl. 12, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 30 de dezembro de 2.021, por volta das 08h15min, na Rua Pernambuco, 181, Vila Popular, Várzea Paulista, tinha em depósito e guardava, para o fim de tráfico e para entrega ao consumo de terceiros, porções de Cannabis Sativa L, com peso aproximado de 1.219g, e um pé de Cannabis Sativa L, com peso aproximado de 888g, substância esta entorpecente e capaz de determinar a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 21 de janeiro de 2.022 (fls. 75/77) e recebida em 26 de janeiro de 2.022 (fls. 82/83).

Devidamente citado, Marcelo apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 96 e fls. 112/119).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 120/121).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Marcelo (fls. 147/148 e

149/150).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Marcelo condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 145/146).

Em memoriais escritos, o defensor requereu seja Marcelo absolvido (fls. 154/159). É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal., dispõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso do tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", a consumação do crime protraí-se no tempo. Trata-se de crime permanente. Constitui, em tese, uma exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.

Em julgado da Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ficou assentado que:

"inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio" (DJe 03/09/2015).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial "a posteriori".

...

a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616 - Rel. Min. GILMAR MENDES - TRIBUNAL PLENO - j. 05/11/2015).

Consta do boletim de ocorrência que os fatos teriam ocorrido em 30.12.21, às 08h15min (fl. 20).

No presente caso, o policial civil e o guarda municipal ingressaram no imóvel por determinação judicial e durante o dia (decisão de fls. 20/21 dos autos em apenso que tramitaram sob número 1503289-49.2021.8.26.0544).

É evidente, pois, que não se pode argumentar que houve entrada forçada em domicílio (art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal).

Ultrapassada essa questão, passo a analisar o mérito da presente ação penal.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, com o laudo de constatação de fls. 26/27, que resultou positivo para a substância Cannabis Sativa L e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/140, igualmente positivo para a substância mencionada.

A autoria é certa.

Em Juízo, Marcelo declarou que "esse mandado de prisão de roubo "foi uma moto que um amigo meu comprou e não sabia que era roubada. "Nós dois caímos e fomos presos, mas eu fui solto porque a vítima não me reconheceu como autor do roubo". Eu sou usuário de entorpecentes desde os 16 anos de idade. A quantia de R\$ 248,00

apreendida estava em minha carteira. "Era o pagamento pelo serviço". Um amigo prometeu-me que pagaria R\$ 300,00 para que eu guardasse aquela droga. Eu precisava do dinheiro e decidi fazer o serviço. Ele não determinou o tempo que eu ficaria com a droga. Ele pagou R\$ 300,00 em dinheiro e deixou que eu ficasse com 200g da droga, em pagamento pelo serviço prestado. Meu amigo chama-se Bruno. Ele mora "três ruas perto de casa". Eles apresentaram a maconha na Delegacia de Polícia e eu fui para o corrô. Não havia um rádio HT e celulares dentro da sacola que eu recebi de Bruno. Eu olhei dentro da sacola, porque eu fui retirar "minha parte - 200g". Eu fiz isso na frente de Bruno. Eu lembro que "não tinha rádio comunicador, celulares, nada." Eu não tinha um simulacro de arma de fogo em minha casa. Não havia um simulacro de arma de fogo dentro da sacola. Eu nunca fui processado ou condenado anteriormente. Eu moro no local com minha mãe. Eles encontraram "umas peças de roupa de minha namorada em minha casa porque ela dorme em casa de vez em quando". Eu acompanhei as diligências realizadas dentro de minha casa. Eu posso garantir que eles não encontraram aparelhos de telefone celular e um simulacro de arma de fogo "porque não tinha isso lá".

A versão apresentada por Marcelo não está completamente dissociada da prova coligida.

Luiz Fabiano, policial civil, informou que no dia dos fatos "nós fomos à residência do réu cumprir um "mandado de busca e apreensão de um roubo". O réu não estava no local. Ele chegou um pouco depois. No guarda-roupa foi encontrada certa quantidade de drogas, folhas de anotações de tráfico, um rádio HT, quatro aparelhos de telefone celular, um certa quantia em dinheiro e embalagens para a droga. Eu não lembro como estava acondicionada a droga. Eu acho que o entorpecente estava dentro de uma sacola. Havia algumas porções já fracionadas para a venda. O réu disse que "a droga era dele, para o consumo". Havia um pé de maconha que foi apreendido. Nós encontramos um quilo de maconha. "Só tinha o réu no local". Não dava para saber se a casa era habitada. Eu não lembro o que havia nas folhas que faziam parecer que eram "anotações de tráfico". Tinha um pé de maconha no vaso. Eu não lembro se o pé de maconha estava dentro ou fora da casa. Nós encontramos R\$ 200,00 dentro da sacola onde estava a droga. O réu não explicou qual a procedência da quantia em dinheiro encontrada naquela sacola. Eu não lembro se as porções estavam ou não prontas para a venda. Eu não lembro se nós encontramos saquinhos ou eppendorfs na casa do réu. O réu disse que não sabia a quem pertenciam o rádio HT e os quatro aparelhos de telefone celular encontrados no local. Havia peças de roupas masculina dentro do armário. O réu admitiu que morava no local. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. A diligência foi acompanhada pela Guarda Municipal. Nós pedimos apoio à Guarda Municipal para que nós pudemos dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido."

Eduardo, guarda municipal, informou que "nós fomos solicitados para prestar apoio à Polícia Civil. Nós prestamos apoio à Polícia Civil que precisava cumprir um mandado de busca e apreensão. O réu não estava em casa quando nós chegamos. Ele chegou pouco depois e franqueou a entrada. Eu entrei na residência do réu com o policial civil Luiz Fabiano. A casa era habitada. O réu morava nos fundos do imóvel. O réu admitiu que as drogas eram dele. Eu localizei quatro aparelhos de telefone celular, 7 folhas de contabilidade do tráfico, um rádio comunicador, um simulacro de arma de fogo, um saco de maconha e um pé de maconha dentro do armário. As anotações continham uma contabilidade. O réu admitiu que os entorpecentes eram dele. Eu não lembro se a droga estava ou não fracionada. "Parece-me que a droga ainda não estava fracionada". Eu não lembro se havia uma grande quantidade de embalagens plásticas para embalar o entorpecente. Havia "um pé de maconha dentro de um vaso pequeno. O pé estava bem pequeno". Parece que o réu estava envolvido na prática de uns crimes de roubo. Nesse armário eu encontrei dois capacetes, a jaqueta preta, o simulacro de arma de fogo e quatro celulares. O réu afirmou que a droga "era para uso próprio". "Das outras coisas, ele não falou". Eu não lembro se nós encontramos alguma quantia em dinheiro com o réu ou dentro do armário. O réu morava naquele local com uma namorada. O vaso com o pé de maconha estava "junto ali, dava a impressão que ia sair dali". Eu não lembro de ter encontrado uma balança de precisão no local."

Pois bem.

O policial civil e o guarda municipal relataram como se deu a apreensão dos entorpecentes. Luiz Fabiano recordou-se de ter apreendido determinada quantia em dinheiro (R\$ 200,00) que, segundo informou, estava dentro da sacola onde estava a droga.

Ao ser ouvido em juízo, Marcelo admitiu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Disse que estava precisando de dinheiro e aceitou guardar a droga para Bruno, um amigo. Aduziu que Bruno pagou R\$ 300,00 e 200g de maconha pela empreitada.

No presente caso, é o que basta para reconhecer o envolvimento de Marcelo na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

As questões atinentes à apreensão de quatro aparelhos de telefone celular, de capacetes, de uma jaqueta de cor preta e de um simulacro de arma de fogo serão possivelmente enfrentadas nos autos da ação penal movida para apurar o envolvimento de Marcelo na prática de crimes de roubo. Não deve e não será tratada nesses autos. Em razão disso, esse juízo não deliberará a respeito da destinação a ser dada aos seguintes objetos apreendidos: aparelhos de telefone celular da marca Apple, modelo iPhone, da marca Samsung (dois aparelhos), e da marca Nokia (auto de exibição e apreensão de fl. 04).

É sempre bom lembrar que as versões apresentadas pelo guarda municipal e pelo policial civil não são suspeitas, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Deve ser desconsiderada apenas se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel^a. Min^a. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6^a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

No caso em tela, os relatos apresentados pelo policial civil e pelo guarda municipal não estão dissociados da versão apresentada por Marcelo, à exceção de detalhes concernentes à apreensão do simulacro, do rádio HT e dos aparelhos de telefone celular, dados que não interferem na tipificação do tráfico de entorpecentes (guardar e ter em depósito), único crime aqui tratado.

De igual modo, não há como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Marcelo admitiu que é usuário de drogas desde os 16 anos de idade. Informou ter optado por se envolver com o tráfico porque estava passando por dificuldades financeiras. O fato de o réu ser ou não usuário/viciado não autoriza a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, a absolvição de Marcelo se impõe.

Passo a dosar a pena de Marcelo.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração da pena-base nesta primeira fase de fixação. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, visto que o agente confessou a prática desse crime. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de diminuir a pena nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. A quantidade de entorpecente apreendido (mais de um quilo de maconha) deve ser considerada para justificar que a redução da pena não se dê no máximo permitido (2/3). A pena deve ser reduzida da metade, totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A despeito da gravidade do crime praticado e mesmo se considerado que o acusado guardava uma grande quantidade de entorpecente (maconha) e embalagens, entendo que é possível substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito indicadas no art. 43 do Código Penal.

Marcelo assim agiu por estar passando por dificuldades financeiras. A prisão em nada o favorecerá.

Dito isso e como estão preenchidos, em tese, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação pecuniária, em valor equivalente a dois salários mínimos, a ser pago a uma entidade pública ou privada com destinação social, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução.

Como a pena fixada é superior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, deve esta ser substituída por duas penas restritivas de direitos, ou por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa.

Por conseguinte, sem prejuízo da prestação pecuniária, substitui-se a pena privativa de liberdade também por uma pena de 20 (vinte) dias-multa, a ser aplicada cumulativamente àquela abstratamente fixada no tipo penal.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, tendo em vista que a sanção aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário, tudo em consonância com disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, RG nº 57.233.024, CPF nº 485.875.678-19, filho de Ismael de Souza Rodrigues e de Marineide Josefa da Conceição, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime aberto, que é substituída por uma pena de prestação pecuniária em valor equivalente a dois salários mínimos, e por uma pena de multa fixada em 20 (vinte) dias-multa.

Marcelo poderá apelar em liberdade, pois é primário, ostenta bons antecedentes e não há nada que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida com Marcelo, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino sejam destruídos rádio comunicador HT da marca BAOFENG, o carregador, as anotações e as embalagens apreendidas.

Comunique-se a D. Autoridade Policial e ao Setor de Armas e Objetos dessa comarca.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Marcelo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Marcelo.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 19 de maio de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA